

学生A及びBは、過剰防衛に関する次の【事例】について、後記【会話】のとおり議論している。【会話】の中の①から④までの()内から適切なものを選んだ場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【事例】

- I. 甲は、同じ居室にいた乙が机を押し倒してきたため、反撃として、同机を乙に向けて押し返した。これにより、乙は転倒し、左手中指の腱を断裂した。乙は、机の下敷きになっており、直ちに強い攻撃はできなかったが、体勢を立て直せば間もなく攻撃を再開できる状況であった。甲は、引き続き、防衛の意思で、必要な限度を超えて、乙の顔面を殴ったが、これにより乙に怪我は生じなかった。
- II. 甲は、乙からいきなり殴られ、更に攻撃を加えられそうになったので、反撃として、乙の顔面を殴った。乙は転倒して頭部を地面に打ち付け、意識を失って動かなくなったが、腹が立っていた甲は、引き続き、専ら攻撃の意思で、倒れている乙の胸部を蹴り付け、肋骨骨折を負わせた。その後、乙は、頭部を地面に打ち付けた際に生じた脳内出血が原因で死亡した。

【会話】

学生A. Iの事例で、甲が机を押し返した行為は、急迫不正の侵害に対する反撃だけど、その行為と乙の顔面を殴った行為との関係は、どのように考えるべきだろうか。

学生B. その点は、時間的・場所的な関係や甲の主観面等に照らし、①(a. 別個の行為・b. 一連一体の行為)と捉えるべきだろう。

学生A. そうすると、甲には、どのような犯罪が成立するだろうか。

学生B. 甲には、②(c. 過剰防衛としての傷害罪が成立する・d. 暴行罪のみが成立する)だろう。

学生A. IIの事例でも、甲が乙の顔面を殴った行為は、急迫不正の侵害に対する反撃であることに変わりないよね。甲には、どのような犯罪が成立するだろうか。

学生B. 乙が意識を失って動かなくなっているのに、専ら攻撃の意思で蹴り付けているのだから、顔面を殴る行為と胸部を蹴り付ける行為の間には断絶があると思う。甲には、③(e. 過剰防衛としての傷害致死罪が成立する・f. 傷害罪のみが成立する)という結論が妥当だろう。

学生A. IIの事例で、B君のように、両暴行の間に断絶があると解すると、④(g. 違法性が否定されるべき行為が遡って違法と評価されることになる・h. 専ら攻撃の意思で胸部を蹴り付けた場合の方が、防衛の意思で胸部を蹴り付けた場合より軽い罪が成立する)という問題が生じるのではないか。

学生B. その点は、量刑上考慮すれば足りるという説明が可能なのではないか。

1. ①a ③e 2. ①b ④g 3. ②d ③e 4. ②c ④g 5. ③f ④h

No89	過剰防衛	正答率
R2-3	正解	86%

() には順に、「① = b、② = c、③ = f、④ = h」が入り、したがって、正解は肢5となる。

①②について

①には、事例Ⅰにおける、甲が乙に向けて机を押し返した第1行為と乙の顔面を殴った第2行為の関係が、②には、第1行為と第2行為の関係を踏まえた甲の罪責に関する語句が入る。第1行為と第2行為を別個の行為と捉えれば、第1行為によって左手中指の腱断裂という傷害結果が発生しており、傷害罪(204条)の構成要件に該当するも、正当防衛(36条1項)により不可罰となるが、第2行為につき顔面を殴打した行為につき暴行罪(208条)のみが成立することになる。他方、第1行為と第2行為を一連一体のものと捉えれば、第1行為及び第2行為全体から左手中指の腱断裂という傷害結果が発生しているので傷害罪(204条)の構成要件に該当する。そして、「乙は、机の下敷きになっており、直ちに強い攻撃はできなかったが、体勢を立て直せば間もなく攻撃を再開できる状況であった」ので、急迫不正の侵害が継続しているところ、甲は、防衛の意思を有しているが、必要な限度を超えて第2行為に及んでいるので、過剰防衛としての傷害罪が成立する(204条、36条2項)ことになる。甲の第1行為と第2行為を一連一体のものとするか、別個のものとするかについて、学生Bが、「時間的・場所的な関係や甲の主観面等に照らし」と述べている(第1発言)だけであり、いずれかは決めがたい。もともと、事例Ⅰと同様の事案において、判例(最決平21.2.24)は、「被告人が被害者に対して加えた暴行は、急迫不正の侵害に対する一連一体のものであり、同一の防衛の意思に基づく1個の行為と認めることができるから、全体的に考察して1個の過剰防衛としての傷害罪の成立を認めるのが相当である」としている。したがって、①には「b. 一連一体の行為」が、②には「c. 過剰防衛としての傷害罪が成立する」が入る。

③について

③には、事例Ⅱにおける、甲の罪責に関する語句が入る。学生Bは、事例Ⅱについて、甲が乙の顔面を殴った第1行為と、乙の胸部を蹴りつけた第2行為の間には断絶があると述べている(第3発言)。そうすると、第1行為については正当防衛(36条1項)が成立し不可罰となるが、第2行為については肋骨骨折を負わせた点で傷害罪(204条)が成立するので、結論としては、甲には傷害罪のみが成立することになる。したがって、③には「f. 傷害罪のみが成立する」が入る。なお、事例Ⅱと同様の事案において、判例(最決平20.6.25、百選Ⅰ27事件)は、「第1暴行により転倒した甲が、被告人に対し更なる侵害行為に出る可能性はなかったのであり、被告人は、そのことを認識した上で、専ら攻撃の意思に基づいて第2暴行に及んでいるのであるから、第2暴行が正当防衛の要件を満たさないことは明らかである。そして、両暴行は、時間的、場所的には連続しているものの、甲による侵害の継続性及び被告人の防衛の意思の有無という点で、明らかに性質を異にし、被告人が前記発言をした上で抵抗不能の状態にある甲に対して相当に激しい態様の第2暴行に及んでいることにもかんがみると、その間には断絶があるというべきであって、急迫不正の侵害に対して反撃を継続するうちに、その反撃が量的に過剰になったものとは認められない。そうすると、両暴行を全体的に考察して、1個の過剰防衛の成立を認めるのは相当でなく、正当防衛に当たる第1暴行については、罪に問うことはできないが、第2暴行については、正当防衛はもとより過剰防衛を論ずる余地もないのであって、これにより甲に負わせた傷害につき、被告人は傷害罪の責任を負うというべきである」としている。

④について

④には、事例Ⅱにおける学生Bの結論に対する学生Aからの批判に関する語句が入る。学生Bは、事例Ⅱで第1行為と第2行為の断絶を認める理由として、「乙が意識を失って動かなくなっているのに、専ら攻撃の意思で蹴り付けている」ということを挙げている。学生Bの考え方からすると、事例Ⅱにおいて、専ら攻撃の意思で胸部を蹴りつけても、結論として第2行為の傷害罪のみが成立するのに対し、仮に、防衛の意思で胸部を蹴りつければ断絶が認められず、第1行為と第2行為が一連一体の行為と評価される結果、傷害致死罪が成立し、過剰防衛となる。そのため、専ら攻撃の意思で反撃した場合のほうが、防衛の意思をもって反撃した場合よりも軽い罪が成立する点で問題であるとの批判が可能となる。したがって、④には「h. 専ら攻撃の意思で胸部を蹴り付けた場合の方が、防衛の意思で胸部を蹴り付けた場合より軽い罪が成立する」が入る。なお、本問は、①②で解答が決められなかったとしても、③f④hと決まった時点で、肢1から肢4が切れ、肢5のみが残る。